

1008247-37.2022.8.26.0048

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Energia Elétrica

Magistrado: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

2ª Vara Cível

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008247-37.2022.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008247-37.2022.8.26.0048

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Energia Elétrica

Impetrante:

Universo do Gelo Comércio Ltda

Impetrado:

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Octaviano Diniz Junqueira

Vistos.

UNIVERSO DO GELO COMÉRCIO LTDA impetrou mandado de segurança contra o ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que não deveria incidir ICMS sobre o montante de energia contratado, mas somente sobre o efetivamente consumido. Requer a declaração da base de cálculo sobre a UC n. 44102666, e o direito ao crédito sobre os valores recolhidos em excesso.

Determinada a emenda da inicial para correção do polo passivo (fl. 44).

Alterou-se para fazer constar FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 47/48).

Determinada a inclusão do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e deferiu-se a liminar para que a autoridade coatora se absteresse de efetuar cobranças do imposto sobre a fatura da energia contratada (fls. 49/52).

A FESP requereu o ingresso nos autos (fl. 62).

Transcorrido o prazo legal, sem defesa (certidão - fl. 63).

O Ministério Público declinou de se manifestar nos autos (fls. 71/72).

É o relatório. Passo a decidir.

Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a sociedade empresária impetrante insurge-se contra incidência de ICMS sobre a reserva de demanda de energia contratada, não tendo sido efetivamente consumida.

Defiro o ingresso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no presente feito na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 7.º, inciso II, parte final, da Lei n.º 12.016/09. Anote-se.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, mostrando-se dispensável maior elaboração probatória, considerando ainda a revelia, com fulcro no art. 355, inciso II, c.c artigo 344, ambos do Código de Processo Civil.

Inicialmente, afasta-se eventual discussão acerca da legitimidade ativa da autora, conforme decisão o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo n.º 1.299.303/SC:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. - Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. - O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica aos casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1299303/SC, Primeira Seção, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 14/08/2012).

Como cediço, o ICMS caracteriza-se como tributo incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias. O fato gerador é a saída do estabelecimento do contribuinte, sendo devido o imposto somente com a entrega ao seu destinatário, quando ocorre a efetiva transferência da posse ou propriedade. O efetivo consumo, pelo destinatário final, é imprescindível para a caracterização do fato gerador do tributo.

O artigo 1º da Lei Estadual nº 6.374/89 estabelece que:

Artigo 1º - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre: (Redação dada ao artigo pela Lei 10.619/00, de 19-07-2000; DOE 20-07-2000) I- operação relativa à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento; (...)

Como a base de cálculo do ICMS tem como fato gerador circulação de mercadoria, em se tratando de energia elétrica, somente é tributável o seu efetivo consumo, consoante anota Roque Antonio Carrazza:

"(...). A base de cálculo possível do ICMS incidente sobre energia elétrica é o valor da operação da qual decorra a entrega desta mercadoria (a energia elétrica) ao consumidor. Noutro giro, é o preço da energia elétrica efetivamente consumida, vale dizer, o valor da operação da qual decorra a entrega desta mercadoria ao consumidor final. Isto corresponde, na dicção do art. 34, § 9.º, do ADCT, ao "preço então praticado na operação final". Descendo a detalhes: a base de cálculo do ICMS-Energia Elétrica é o "valor de que decorrer a saída da mercadoria", conforme, aliás, dispõe a legislação ordinária de todos os Estados-membros e do Distrito Federal (v.g., o art. 24 da Lei paulista 6.374/1979). A própria Lei Complementar 87/1996 está afinada neste diapasão (art. 13, I). (...). Repisando argumentos já

exibidos, sendo o ICMS-Energia Elétrica uma modalidade de imposto sobre operações mercantis, sua base de cálculo somente pode ser o valor da operação de fornecimento desta mercadoria. (Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 15. Ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 303-304 - destaquei em negrito).

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido nos autos do Recurso Especial nº 960.476/SC (Tema n.º 63, em que se questionava a legitimidade da cobrança de ICMS sobre o valor pago a título de "demanda contratada" de energia elétrica), processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o ICMS incide apenas sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor:

TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa". 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência". Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 960.476/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 13/5/2009).

O STF julgou o RE 593.824/SC, processo-paradigma do Tema n.176 com trânsito em julgado em 25/02/2021, fixando a seguinte tese:

"A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor".

Aplica-se, ainda, ao caso em análise, a Súmula nº 391 do E. STJ:

"O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Dessa forma, inexigível o ICMS incidente sobre o valor contratual da demanda reservada de energia elétrica, por vício na base do fato gerador.

Logo, diante da ilegalidade, independentemente de se tratar de contrato de consumo cativo ou livre, resta demonstrado o direito líquido e certo alegado e lesado, de modo que a concessão da segurança se impõe.

Consequentemente, cabível o pedido restituição dos valores cobrados em excesso, abrangendo o prazo quinquenal retroativamente, a contar-se do ajuizamento do

mandamus.

Contudo, não é possível aqui a compensação de crédito tributário (artigos 156, II, e 170 do CTN), haja vista inexistir pedido administrativo prévio, e haver entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que seria necessária lei prévia que a autorizasse, inexistente no Estado de São Paulo (e inaplicável a Lei 6.374/89, por não se confundirem os créditos escriturais com créditos decorrentes do pagamento considerado indevido por sentença judicial, não importando em contrariedade à Súmula 213 do STJ, conforme explicitado no julgamento do Tema 118 do STJ).

Em se tratando de declaração de inexigibilidade combinada com repetição de indébito de tributo estadual, deve incidir correção monetária, desde o desembolso, pelo IPCA-E até o trânsito em julgado (Tema 810 do STF), bem como, a partir de então, a aplicação da taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 188, editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça e o disposto no artigo 1º da Lei Estadual n. 10.175/98.

Aliás, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, acumulado mensalmente.

Ante ao exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange a demanda reservada de energia elétrica, ressaltando que o fato gerador é a potência efetivamente utilizada e DETERMINAR à requerida que restitua as diferenças apuráveis, nos últimos cinco anos, atualizas monetariamente.

Servirá esta sentença como ofício à autoridade impetrada, dando-lhe conhecimento desta decisão para as providências necessárias.

Isenta de taxas e emolumentos, deixo de condenar a autoridade coatora a pagar honorários advocatícios em razão das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e artigo 25 da Lei n.º 12.016/09.

Decisão sujeita à remessa necessária (art. 496, CPC). Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Seção de Direito Público, nos termos do artigo 14, § 1.º, da Lei n.º 12.016/09.

No momento oportuno e feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.

Atibaia, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA